

Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT

Nummer 7130/212; 7131/219

Betreft zaak: taxivervoer Rijnmond/IJsselsteden de heer A

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 62 van de Mededingingswet.

I. Inleiding

1. Op 28 april 2011 heeft de Directie Mededinging van de Nederlandse Mededingingsautoriteit aan Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V. (hierna: RMC) en IJsselsteden Beheers Groep B.V. (hierna: IJsselsteden) respectievelijk Bios Rijnmond Beheer B.V. haar aandeelhouders en haar dochterondernemingen BIOS Personenvervoer B.V., Zorgvervoercentrale Nederland B.V. en Taxicentrale Middelburg B.V. (hierna tezamen: BIOS-groep) rapporten in zaak 7130, respectievelijk 7131, toegezonden wegens het vermoeden van het overtreden van de Mededingingswet (hierna: Mw) door deze ondernemingen.
2. Dezelfde rapporten zijn ook gezonden naar de natuurlijke personen van wie werd vermoed dat zij feitelijk leiding hebben gegeven aan de overtredingen onder wie de heer [A] (hierna: de heer [A] en in e-mails ook [vertrouwelijk] van RMC.
3. Dit besluit betreft de heer [A], [leidinggevende] van RMC.
4. Bijlage 1 bevat het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad), kenmerk 7130/153, in welk besluit de Raad heeft vastgesteld dat RMC en IJsselsteden in de periode van 18 december 2007 tot en met 27 augustus 2010 artikel 6 Mw hebben overtreden. Deze bijlage, inclusief de daarin gedefinieerde termen, maakt integraal onderdeel uit van dit besluit.
5. Bijlage 2 bevat het besluit van de Raad, kenmerk 7131/168, in welk besluit de Raad heeft vastgesteld dat RMC en BIOS-groep in de periode van 17 april 2009 tot en met 1 maart 2011 artikel 6 Mw hebben overtreden. Deze bijlage, inclusief de daarin gedefinieerde termen, maakt integraal onderdeel uit van dit besluit.

II. Juridisch kader

6. Artikel 56 Mw luidt, voor zover van belang, als volgt:

1. Ingeval van overtreding van artikel 6, eerste lid (...), kan de raad de overtreder:
 - a. een bestuurlijke boete opleggen;(...).

7. Artikel 5:1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) luidt als volgt:

(...)

3. Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Artikel 51, tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige toepassing.

8. Artikel 51, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) luidt als volgt:

2. Indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de strafvervolgung worden ingesteld en kunnen de in de wet voorziene straffen en maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, worden uitgesproken:
 1. tegen die rechtspersoon, dan wel
 2. tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelijke leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel
 3. tegen de onder 1° en 2° genoemden tezamen.

9. Een natuurlijke persoon kan beboetbaar leiding geven aan een overtreding van een onderneming of ondernemersvereniging door actieve gedragingen, waarbij de overtreding door hem wordt bevorderd door middel van handelen, alsook door passieve gedragingen, waarbij de natuurlijke persoon de overtredingen doet bevorderen door nalaten.¹

10. Uit de jurisprudentie volgen minimumcriteria wanneer in ieder geval sprake is van leiding geven in de zin van 51 Sr:

“Van feitelijk leiding geven aan verboden gedragingen kan onder omstandigheden sprake zijn indien de desbetreffende functionaris — hoewel daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden — maatregelen ter voorkoming van deze gedragingen achterwege laat en bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedragingen zich zullen voordoen. In deze situatie wordt de

¹ Vergelijk Hoge Raad 20 november 1984, NJ 1985, 355. Zie ook recentelijk Rechtbank Rotterdam 16 mei 2012, LJN: BW 6221.

zojuist bedoelde functionaris geacht opzettelijk de verboden gedragingen te bevorderen”.²

11. De verplichting om maatregelen te nemen ter voorkoming van een bepaalde gedraging, kan op meerdere natuurlijke personen tegelijkertijd rusten.³ In zo een geval kan aan één gedraging van de rechtspersoon door meerdere personen tegelijkertijd leiding worden gegeven.
12. Het leidinggeven vereist volgens vaste jurisprudentie dat sprake is van (voorwaardelijk) opzet. Daartoe is in het geval van een overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw voldoende dat sprake is van opzet op de gedragingen van de onderneming.⁴ Niet van belang is of degene die kennis heeft van de gedragingen beoogt een norm te overtreden. Een dergelijke verzwaarde vorm van opzet is niet vereist.⁵
13. De Raad heeft in zijn besluiten met kenmerk 7130/153 en 7131/168 geconcludeerd dat RMC artikel 6, eerste lid, Mw heeft overtreden. In het onderhavige besluit is aan de orde of de heer [A] daaraan feitelijk leiding heeft gegeven als bedoeld in artikel 5:1, derde lid, van de Awb, gelezen in samenhang met artikel 51, tweede lid, Sr.⁶

III. Feiten en omstandigheden

III.1. Zaak 7130 RMC- IJsselsteden

14. De Raad stelt in aanvulling op het sanctiebesluit met kenmerk 7130/153, waarin een overtreding van artikel 6 Mw door RMC is vastgesteld (bijlage 1), de navolgende feiten en omstandigheden vast.
15. In de periode van 18 december 2007 tot en met 27 augustus 2010 voerde de heer [A] samen met de heer [B] de [vertrouwelijk] van RMC. De heer [A] is sinds 2004, en ook in bovengenoemde periode, [leidinggevende] van RMC en in die hoedanigheid [vertrouwelijk]. Ten aanzien van zijn functie heeft de heer [A] verklaard:

“[vertrouwelijk]”.⁷

² Hoge Raad 16 december 1986, *NJ*1987, 321 (*Slavenburg II*), r.o. 5.1.1.

³ Hoge Raad 16 juni 1981, *NJ*1981, 586 (*Papa Blanca*), r.o. 8.

⁴ Hoge Raad 1 februari 2005, *NJ*2006, 421 (*SE Fireworks*), r.o. 7.5 en 7.6; Hoge Raad 12 januari 2010, *RvdW*2010, 168, r.o. 2.5.

⁵ Hoge Raad 18 maart 1952, *NJ*1952, 314, bevestigd in Hoge Raad 27 april 2007, *NJ*2007, 544, r.o. 3.3.

⁶ De Raad beschouwt opdracht geven als een bijzondere vorm van feitelijk leidinggeven en volstaat derhalve met de algemene term “leidinggeven”.

⁷ Dossierstuk 46, met kenmerk 7130_34 en dossierstuk 53 met kenmerk 7131_42, p.1.

16. De Raad stelt vast dat de heer [A] direct betrokken is geweest bij de totstandkoming op 18 december 2007 van de afspraken die de basis vormen van de overtreding van RMC. De Raad leidt dit af uit een interne e-mail van de heer [A] van 17 december 2007 aan onder andere de heer B (RMC), met als bijlage de ‘conceptsamenwerkings-overeenkomst IJsselsteden’, waarin het volgende staat:

“Ik heb vanmiddag een vervolggesprek gehouden met IJsselsteden en alle onderwerpen doorgesproken, t/m aanbesteding VOM, etc. Ik wil dit verhaal morgenochtend doorsturen aan [de heer C] en [de heer D] en liefst die zelfde dag nog laten tekenen. Dus als het kan gaarne reactie voor 10:00 uur”.⁸

17. Vervolgens heeft de heer [A] op 18 december 2007 meerdere malen contact met de heren [C] en [D] (beide van IJsselsteden) over de conceptovereenkomst.⁹

“[vertrouwelijk], “[vertrouwelijk], [NMa: de heren C en D]

Hierbij de versie die eigenlijk aan jullie had moeten versturen.

Deze heb ik aangepast op basis van mijn tel. Gesprekje met [vertrouwelijk].

Ik hoor graag verder van jullie.

Mvrgr.

A”.¹⁰

“Beste “[vertrouwelijk], “[vertrouwelijk], [NMa: de heren C en D]

Ik heb jullie laatste wens verwerkt in een extra alinea bij punt 9.

Tevens nog even een enkele tekstfout (o.a. bij de tenaamstelling) verbeterd.

Als jullie morgen laten weten of we er dan zoals verwacht definitief uit zijn, dan is het voor ons allen misschien leuk om nog voor de Kerst te tekenen.

Mvrgr.

A”.¹¹

⁸ Dossierstuk 59, 7130_41, bijlage 2.

⁹ Dossierstuk 59, 7130_41: verslag van opname, digitaal document nr. 2: e-mail van de heer [A] aan onder andere de heer [B] d.d. 17 december 2007, afkomstig van bedrijfsbezoek RMC/RTC.

¹⁰ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130_41, bijlage 4.

¹¹ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130_41, bijlage 5.

18. Over zijn betrokkenheid bij de totstandkoming van de overeenkomst heeft de heer [A] verklaard:

“U vraagt mij of er nog andere personen betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze overeenkomst. Ik heb de indruk dat ikzelf die voorbereiding alleen heb gedaan, maar ik kan me dat niet zo goed herinneren”.¹²

19. De heer [A] heeft in zijn hoedanigheid als [leidinggevende] van RMC de overeenkomst van 18 december 2007 met IJsselsteden ondertekend.¹³

20. De Raad stelt vervolgens vast dat de heer [A] direct betrokken is geweest bij de uitvoering van de afspraken tussen RMC en IJsselsteden inzake de aanbestedingen in de periode 18 december 2007 tot en met 27 augustus 2010. De Raad leidt dit af uit de volgende e-mailwisselingen.

21. Op 19 augustus 2008 ontvangt de heer [A] een afschrift van een e-mailwisseling tussen een medewerker van RMC en de heer [C] over de aanbesteding Leerlingenvervoer Capelle.

“[vertrouwelijk], [NMa: medewerker van RMC]

(..)

De afspraak was ieder eigen gebied (Onderstreping NMa) dus dit valt onder mij ik heb Breda al gegund gekregen dus gaarne niet onder de prijs door er licht ook een offerte voor de andere ritten en den haag gaat ook apart

(..)

Dus conform afspraak (Onderstreping NMa) graag.

Ik stuur cc “[vertrouwelijk] [NMa: de heer A]

[C]”¹⁴

22. Uit een andere e-mailwisseling blijkt dat de heer [C] refereert aan de tussen RMC en IJsselsteden gesloten overeenkomst van 18 december 2007.

“[vertrouwelijk] [NMa: medewerker van RMC]

Dit is wel de afspraak ik rij die zoetermeer [SIC] ed en voorts al tijden tot vorig jaar hebben juli [SIC] ze gereden daarna is er een overeenkomst de datum 18 dec 2007 (Onderstreping NMa) gemaakt als juli [sic] Die afspraak niet kunnen of willen nakomen dan is het ons ook vrij om

¹² Dossierstuk 46, met kenmerk 7130_34 en dossierstuk 53, met kenmerk 7131_42.

¹³ Dossierstuk 60, met kenmerk 7130_42, bijlage 1.

¹⁴ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130_41, bijlagen 10 en 23.

op vom in te schrijven ik denk dat dit niet de bedoeling is van onze afspraken. (Onderstreping NMa)

Met vriendelijke groet,

“[vertrouwelijk]”.¹⁵ [NMa: de heer [C]]

23. In april 2009 volgt een e-mailwisseling tussen de heren [A] en [B] (IJsselsteden) over de uitkomst van de aanbesteding Vervoer op Maat 2008 (VOM), waaruit de betrokkenheid van de heer [A] bij de verboden afspraken volgt.¹⁶

“Goedemiddag “[vertrouwelijk], [NMa: de heer A]

Tot op dit moment hebben wij nog geen enkel teken van leven gezien van de kant van Connexxion aangaande het Achmea Zittend Ziekenvervoer in Rotterdam. (..) Dit impliceert dan wel dat wij, volgens afspraak, (Onderstreping NMa) per 1 mei a.s. mee gaan rijden met de afgesproken 10 voertuigen in het VOM project. Met wie of wanneer kunnen hier concrete afspraken over gemaakt worden?

Met groet,

[C]

[D]” (NMa: beiden bestuurder van IJsselsteden)

24. Hierop reageert de heer [A] met de volgende e-mail:¹⁷

““[vertrouwelijk, “[vertrouwelijk], [NMa: de heren [C] en [D]]

Ik heb tijdens de opening van jullie schadeafdeling nadrukkelijk met [vertrouwelijk] afgesproken dat de definitieve keuze nu gemaakt is en dat we nu niet meer gaan veranderen. Wij moeten immers naar de opdrachtgever VOM wel onze zaken voor elkaar hebben en wij hebben de uren en wagens inmiddels toebedeeld aan [vertrouwelijk].

(..)

Met vriendelijke groet,

[A]”

25. De heer [D] reageert daarop volgt:¹⁸

“Goedemorgen “[vertrouwelijk], [NMa: de heer [A]]

(..) Wij hebben begrip voor jullie situatie en begrijpen ook dat er, na wisselingen van de wacht aan de Keenstraat¹⁹, veranderingen zijn ontstaan. Deze veranderingen kunnen er volgens ons echter niet toe leiden dat wij met lege handen achter blijven. Volgens ons zijn wij de in jullie

¹⁵ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130_41, bijlagen 10 en 23.

¹⁶ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130_41, bijlage 12.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ RMC en RTC zijn aan de Keenstraat in Rotterdam gevestigd.

offerte met naam genoemde onderaannemer waarmee de RMC destijds op deze aanbesteding VoM heeft ingeschreven. Deze afspraak volgde destijds voort uit onze toezegging om niet zelf of in combinatie met een of meerdere andere partijen op dit project in te schrijven. Ook is de RMC schriftelijke contractuele afspraken met ons aangegaan om een (gedeelte) van het VoM project i.c.m. met de RMC uit te voeren."(Onderstreping NMa)

26. Ook uit de gang van zaken bij aanbesteding van Leerlingenvervoer Krimpen blijkt dat de heer [A] betrokken is geweest bij de uitvoering van de overeenkomst. Op 1 februari 2010 ontvangt de heer [A] van een medewerker van RMC een e-mail waarin hij wordt gewezen op het feit dat de aanbesteding leerlingenvervoer Krimpen in het gebied van IJsselsteden ligt en dat de heer [A] moet gaan overleggen met IJsselsteden.

“[vertrouwelijk], [NMa: de heer [A]]

Voor het leerlingenvervoer Krimpen, dit ligt in het aanbestedingsgebied van IJsselsteden. Ik neem aan dat jij nog gaat overleggen met de vrienden”.²⁰

27. Op 8 maart 2010 heeft de heer [A] overleg met de heren [C] en [D] over wie welke percelen gaat rijden bij de aanbesteding. De heer [A] schrijft in een interne e-mail het volgende naar aanleiding van dit overleg:

“Beste mensen,

Zojuist nog even gesproken met [C].

(...)

Afgesproken met [vertrouwelijk] dat de RMC inschrijft op beide percelen. IJsselsteden wordt dan onderaannemer voor het noordelijk perceel en RMC rijdt zelf het zuidelijke perceel.

(...)”.²¹

III.II. Zaak 7131 RMC - BIOS-groep

28. De Raad stelt in aanvulling op het sanctiebesluit met kenmerk 7131/168, waarin een overtreding van artikel 6 Mw door RMC is vastgesteld (bijlage 2), de navolgende feiten en omstandigheden vast.
29. De heer [A] is direct betrokken geweest bij de totstandkoming op 17 april 2009 van de afspraken met de BIOS-groep die de basis vormen van de overtreding van RMC. De Raad leidt dit af uit de e-mail die de heer [A] op 30 maart 2009 zendt aan [vertrouwelijk] Notarissen

²⁰ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130_41: bijlage 14.

²¹ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130_41: bijlage 16.

met cc aan de heer [B], de heer [C] en de heer [D] (beiden van de BIOS-groep) inzake een concept voor de overeenkomst in 2009.²²

30. Vervolgens ontvangt de heer [A] op 15 april 2009 van de heer [C] (de BIOS-groep) een voorstel tot aanpassing van de overeenkomst, waarbij hij een alternatieve tekst voorstelt.²³ De heer [A] stuurt het tekstvoorstel van de BIOS-groep op 16 april 2009 per e-mail door aan onder andere de heer [B] met een verzoek om zijn visie op het tekstvoorstel te geven.²⁴ Op 17 april 2009 zendt de heer [A] aan de heer [C] per e-mail een bevestiging dat hij zich volledig kan vinden in de voorgestelde aanpassingen:

*“Ik heb jouw onderstaande mail inmiddels bestudeerd en kan je melden dat ik mij volledig kan vinden in jouw opmerkingen c.q. aanbevelingen inzake de Samenwerkingsovereenkomst. Ik zal deze mail dan ook rechtstreeks doorzetten aan mevr. [vertrouwelijk], zodat zij deze kan verwerken”.*²⁵

31. De heer [A] heeft in zijn hoedanigheid als [leidinggevende] van RMC de overeenkomst van 14 juli 2009 met de BIOS-groep ondertekend.²⁶
32. De Raad stelt vervolgens vast dat de heer [A], na de totstandkoming van de overeenkomst, direct betrokken is geweest bij de uitvoering van de afspraken tussen RMC en de BIOS-groep inzake de aanbestedingen in de periode 17 april 2009 tot en met 1 maart 2011.
33. Uit een e-mail van de heer [A] aan de heer [C] (BIOS-groep) van 5 februari 2010 met als onderwerp “Agenda voor dinsdag” leidt de Raad af dat RMC en de BIOS-groep willen afstemmen over deze aanbesteding van ASVS 2010:²⁷

*“Ik heb van [vertrouwelijk] [NMa: de heer [D] van BIOS-groep] begrepen dat wij dan (los van BTR agenda) in ieder geval nog willen afstemmen over:
- aanbesteding ASVZ”*

34. De heer [A] heeft vervolgens ook daadwerkelijk met de heer [D] (BIOS-groep) overleg gehad over de aanbesteding ASVZ 2010. Dit blijkt onder andere uit een e-mail van de heer [A] van 9 februari 2010 aan onder meer de heer [B] (RMC), waarvan de heer [C] en de heer [D] (beide van BIOS-groep) een afschrift ontvangen. In de e-mail doet de heer [A] verslag van de op die

²² Dossierstuk 67, met kenmerk 7131_50, bijlage 20.

²³ Dossierstuk 67, met kenmerk 7131_50, bijlage 21.

²⁴ Dossierstuk 67, met kenmerk 7131_50, bijlage 33.

²⁵ Dossierstuk 67, met kenmerk 7131_50, bijlage 21.

²⁶ Dossierstuk 16, met kenmerk 7131_25.

²⁷ Dossierstuk 67, met kenmerk 7131_50, bijlage 26.

dag met de BIOS-groep gemaakte afspraken over wie van hen op de aanbesteding ASVZ 2010 inschrijft en op welk perceel:

“De Biosgroep is er toch een voorstander van om zich zelfstandig te kwalificeren voor de pré selectie indien het antwoord op de gestelde vragen n.a.v. de N.V.I aanbesteding daar mogelijkheden toe biedt. (Na de pré selectie kan altijd nog een definitief standpunt worden ingenomen). De Biosgroep wil graag de omzet van het perceel "waarden" via de eigen omzet laten lopen zonder overigens zelf per sé te willen rijden. RMC heeft gewezen op de stellige indruk dat ASVZ beide percelen graag in één hand ziet!”²⁸

35. Vervolgens zendt de heer [A] op 26 april 2010 per interne e-mail de afspraak die hij met de heer [D] (de BLOW-groep) heeft gemaakt aan een medewerker van RMC en zendt deze e-mail gelijktijdig in afschrift aan de heer [D] (de BIOS-groep):

*“De laatste afspraak die ik met [D] gemaakt heb is dat RMC voor beide percelen ging inschrijven en Biosgroep niet”.*²⁹

36. Uit het bovenstaande volgt dat de heer [A] de wetenschap had van de afspraken die de overtreding van RMC en de BIOS-groep vormen. Hij is immers direct betrokken geweest bij de totstandkoming van de overeenkomst. Ook is de heer [A] direct betrokken bij de uitvoering van de verboden afspraken. Vast staat ook dat de heer [A] niets heeft gedaan om de verboden gedraging van RMC en de BIOS-groep te stoppen, hoewel hij hier als [leidinggevende] toe bevoegd en gehouden was.

IV. Zienswijze de heer [A]

37. De heer [A] stelt zich op het standpunt dat de in de rapporten geschetste afspraken geen overtreding vormen van artikel 6 Mw.³⁰ Voor zover al sprake zou zijn van overtredingen door RMC, zou de heer [A] geen opdracht hebben gegeven tot, dan wel feitelijk leiding hebben gegeven aan verboden gedragingen. De door de NMa in de rapporten geschetste afspraken hebben niet tot doel of tot gevolg gehad dat de concurrentie is beperkt, verhinderd of vervalst, aldus de heer A. In ieder geval zou artikel 6 Mw niet gelden omdat de afspraken binnen de grenzen van de bagatelvoorziening van artikel 7 Mw zouden vallen. De heer A verwijst voor een nadere onderbouwing van deze standpunten naar de zienswijze van RMC.

²⁸ Dossierstuk 67, met kenmerk 7131_50, bijlage 27.

²⁹ Dossierstuk 67, met kenmerk 7131_50, bijlage 29.

³⁰ In de zienswijze van RMC wordt verwezen naar hun memo van 15 april 2011 (verzoek om toezeggingsbesluit).

V. Beoordeling

38. De Raad wijst erop dat hij in zijn besluiten met kenmerk 7130/153 en 7131/168, heeft vastgesteld dat RMC artikel 6 Mw heeft overtreden. In die besluiten heeft de Raad bovenstaande argumenten dat er geen sprake zou zijn van mededingingsrechtelijk verboden gedragingen reeds behandeld en weerlegd. Met betrekking tot het feitelijk leidinggeven door de heer [A] oordeelt de Raad als volgt.
39. Gedurende de periode van de overtredingen van RMC was de heer [A] [leidinggevende] van RMC, in welke hoedanigheid [vertrouwelijk]. Hieruit vloeit voort dat de heer [A] de eindverantwoordelijkheid heeft voor [vertrouwelijk] binnen RMC. Daarnaast is de heer [A] specifiek verantwoordelijk [vertrouwelijk] van de onderneming.
40. In zijn hoedanigheid als [leidinggevende] van RMC heeft de heer [A] bij uitstek de hiërarchische en feitelijke positie en de daarbij horende bevoegdheid om gedragingen die leiden tot de overtredingen door RMC te voorkomen, dan wel vervolgens na aanvang van de overtredingen deze te beëindigen of ongedaan te maken.

IJsselsteden

41. De Raad heeft in paragraaf 3.1. van het onderhavige besluit vastgesteld dat de heer [A] direct betrokken is geweest bij de totstandkoming op 18 december 2007 van de afspraken die de overtreding van RMC met IJsselsteden vormen. De heer [A] heeft, in zijn hoedanigheid als [leidinggevende], op 17 december 2007 persoonlijk de besprekingen met IJsselsteden gevoerd over de afspraken, zoals die zijn neergelegd in de overeenkomst van 18 december 2007. Daarna heeft hij deze overeenkomst ook ondertekend.
42. Vervolgens stelt de Raad vast dat de heer [A] direct betrokken is geweest bij de uitvoering van de afspraken tussen RMC en IJsselsteden. De heer [A] heeft in zijn hoedanigheid als [leidinggevende], niet alleen afschriften van e-mailwisselingen tussen RMC en IJsselsteden ontvangen, ook is hij op de hoogte gehouden van de contacten tussen RMC en IJsselsteden. De heer [A] heeft daarnaast persoonlijk contact gehad met IJsselsteden over de uitvoering van de afspraken tussen RMC en IJsselsteden.

BIOS-groep

43. De Raad heeft in paragraaf 0 van het onderhavige besluit vastgesteld dat de heer [A] direct betrokken is geweest bij de totstandkoming op 17 april 2009 van de afspraken die de overtreding van RMC vormen. De heer [A] heeft in april 2009 persoonlijk de besprekingen met de BIOS-groep gevoerd over de afspraken, zoals die zijn neergelegd in de overeenkomst van 14 juli 2009. Daarna heeft hij deze overeenkomst ook ondertekend.

44. De heer [A] is voorts direct betrokken geweest bij de uitvoering van de afspraken tussen RMC en de BIOS-groep. De heer [A] heeft in zijn hoedanigheid als [leidinggevende], niet alleen afschriften van e-mailwisselingen tussen RMC en de BIOS-groep ontvangen, ook is hij op de hoogte gehouden van de contacten tussen RMC en de BIOS-groep. De heer [A] heeft ten slotte persoonlijk contact gehad met de BIOS-groep over de uitvoering van de afspraken tussen RMC en de BIOS-groep.

Conclusie

45. Naar het oordeel van de Raad staat op basis van het voorgaande vast dat de heer [A] direct betrokken is geweest bij de gedragingen van RMC die de Raad als overtredingen van artikel 6, eerste lid, Mw heeft gekwalificeerd. De heer [A] was voorts zelf bevoegd en daarmee gehouden om een eind te maken aan die gedragingen van RMC. Vaststaat dat de heer [A] de gedragingen van RMC die in strijd zijn met de Mededingingswet niet heeft voorkomen, beëindigd of doen eindigen. Integendeel, na het maken van de afspraken houdt de heer [A] toezicht op de nakoming ervan.
46. Gelet op het bovenstaande stelt de Raad op grond van het handelen van de heer [A] en het nalaten de overtredingen te beëindigen (waartoe hij als [leidinggevende] van RMC was gehouden), vast dat de heer [A] voor de gehele duur van beide overtredingen van RMC hieraan feitelijk leiding heeft gegeven.
47. In het licht van het voorgaande is de heer [A] overtreder in de zin van artikel 5:1, derde lid, Awb.
48. Anders dan de heer [A] in zijn zienswijze lijkt te betogen, hoeft de Raad daarbij niet te onderzoeken of de heer [A] (ook) opdracht heeft gegeven in de zin van artikel 51 Sr. Dit is voor het feitelijk leidinggeven immers geen (noodzakelijk) element.³¹

VI. Verwijtbaarheid

49. Volgens artikel 5:41 Awb legt het bestuursorgaan geen bestuurlijke boete op voor zover de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten. Indien wel sprake is van verwijtbaarheid, stemt het bestuursorgaan ingevolge artikel 5:46 Awb de boete af op – onder andere – de mate van verwijtbaarheid.

³¹ Vgl. Hoge Raad 14 januari 1992 NJ 1992, 413 (*Discotheek Babylon*).

50. Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan de Raad een beroep op afwezigheid van alle schuld honoreren. Degene die hier een beroep op doet, moet hiertoe de omstandigheden aandragen.

Zienswijze de heer [A]

51. De heer [A] is van mening dat hem geen, dan wel verminderd verwijt kan worden gemaakt van de vermeende overtredingen. Hij verwijst ter onderbouwing ten eerste naar de complexe samenwerking van taxiondernemers in RTC en (via RMC) in RMC. In beginsel zijn RTC-leden geen concurrenten voor contractueel taxivervoer. Bij sommige kleine en middelgrote aanbestedingen zouden de grotere leden van RTC echter zelfstandig kunnen inschrijven of als onderaannemer een groter deel van de opdracht behalen dan RMC hen op basis van de verdeelsleutel biedt. Dit (potentiële) tegenstrijdig belang levert binnen RTC spanningen op en brengt grote risico's mee voor het functioneren (en daarmee van de continuïteit) van RTC en RMC. Om die reden hebben RTC en RMC hierover afspraken gemaakt met de leden/aandeelhouders van RTC. Samenwerking is volgens de heer [A] ook nodig om te kunnen komen tot een nieuwe landelijke opererende marktspeeler die tegenwicht kan bieden aan de dominante positie van Connexxion op de relevante markt. De afspraken in de rapporten moeten worden gezien in het licht van dit spanningsveld van concurrentie en noodzakelijke samenwerking.
52. Ten tweede is het volgens de heer [A] voor [vertrouwelijk] RMC bijzonder lastig om te bepalen tot op welke hoogte overleg en samenwerking met andere marktspelers binnen de kaders van het kartelverbod blijven. Zelfs uitgebreid voorafgaand juridisch en economisch onderzoek kan de gewenste duidelijkheid niet geven, aldus de heer [A]. Dat geldt temeer nu het relevante juridisch kader in de periode vanaf 2007 voortdurend aan verandering onderhevig is geweest.

Beoordeling

53. De Raad stelt vast dat de heer [A] dezelfde argumenten aanvoert die RMC heeft aangevoerd in het kader de betwisting van de overtreding door RMC, maar dan in relatie tot zijn rol van feitelijk leidinggever aan de overtreding van RMC. Ten aanzien van deze argumenten heeft de Raad in het besluit jegens de onderneming reeds geoordeeld dat deze geen aanleiding zijn om ten aanzien van de onderneming aan te nemen dat er sprake is van afwezigheid dan wel een verminderde mate van verwijtbaarheid (zie de besluiten met kenmerk 7130/153 en 7131/168).
54. De Raad is van oordeel dat deze gronden evenmin aanleiding zijn om te concluderen dat sprake is van afwezigheid dan wel verminderde mate van verwijtbaarheid bij de heer [A]. Dit geldt temeer nu van de heer [A] als [leidinggevende] vereist en verwacht mag worden dat hij zich vergewist van de (juridische) kaders waarbinnen de onderneming en hijzelf dienen te opereren.

VII. Sanctie

VII.I. Beoordelingskader

55. Op grond van artikel 57, eerste lid, Mw, gelezen in samenhang met artikel 5:1, derde lid, Awb, kan de Raad, wanneer een overtreding gepleegd is door een rechtspersoon, een bestuurlijke boete van ten hoogste EUR 450.000 opleggen aan degenen die tot de overtreding opdracht hebben gegeven of daaraan feitelijk leiding hebben gegeven. De nadere invulling van de factoren waarmee bij de vaststelling van de hoogte van de boete rekening wordt gehouden, is aan de Raad overgelaten. Hierbij dient hij rekening te houden met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
56. Met betrekking tot de hoogte van een boete heeft de Minister van Economische Zaken op grond van artikel 5d Mw beleidsregels vastgesteld om de Raad richting te geven bij de uitoefening van zijn bevoegdheid tot het opleggen van boetes. Omdat de overtreding na 1 oktober 2009 heeft voortgeduurd, zijn de Boetebeleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de NMa 2009 ("Boetebeleidsregels") van toepassing.³²
57. De Raad stelt op grond van artikel 11, tweede lid, van de Boetebeleidsregels een boetegrondslag vast die is gerelateerd aan de ernst van de overtreding en het inkomen en vermogen van de overtreder, teneinde tot een bestuurlijke boete te komen die zowel uit het oogpunt van algemene preventie als uit het oogpunt van specifieke preventie voldoende afschrikwekkend is. De boetegrondslag is de basisboete.
58. Ingevolge artikel 11, vierde lid, onderdeel b, van de Boetebeleidsregels wordt de boetegrondslag voor natuurlijke personen voor het feitelijk leiding geven aan een overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw vastgesteld binnen de bandbreedte van 50.000 - 400.000 euro. De boetegrondslag wordt binnen deze bandbreedte gerelateerd aan de ernst van de overtreding van zowel de rechtspersoon als de feitelijk leidinggever en de inkomens- en vermogenspositie van die feitelijk leidinggever. Voorts neemt de Raad bij de vaststelling van de bestuurlijke boete boeteverhogende en -verlagende omstandigheden in aanmerking.³³

VII.II. Toepassing

59. Onder verwijzing naar de besluiten met kenmerk 7130/153 en 7131/168 staat vast dat RMC zich schuldig heeft gemaakt aan zeer zware overtredingen waarvoor een ernstfactor van 3

³² Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de NMa 2009, *Stcrt.* 2009, nr. 14079.

³³ Artikel 12 Boetebeleidsregels.

respectievelijk 2,5 is vastgesteld. Met betrekking tot de rol van de heer [A] als feitelijk leidinggever daaraan, overweegt de Raad als volgt.

60. Gelet op de positie die de heer [A] inneemt in [vertrouwelijk] RMC en gelet op zijn directe betrokkenheid bij de gedragingen die de overtredingen van RMC vormen, acht de Raad, met inachtneming van de ernst van de overtredingen, een boetegrondslag van EUR 250.000 voor het feitelijk leiding geven aan de overtreding door RMC en IJsselsteden, respectievelijk EUR 200.000 voor het feitelijk leidinggeven aan de overtreding door RMC en BIOS-groep in beginsel passend.
61. De Raad houdt bij het vaststellen van de boetegrondslag eveneens rekening met de inkomens- en vermogenspositie van de feitelijk leidinggever. Omdat het opleggen van een boete voor het feitelijk leidinggeven aan de overtreding uit zaak 7130 gevolgen heeft voor de inkomens- en vermogenspositie van de heer [A] en daarmee voor het opleggen van een boete voor het feitelijk leidinggeven aan de overtreding uit zaak 7131 (en vice versa), is het naar het oordeel van de Raad niet evenredig om voor beide overtredingen afzonderlijk een boetegrondslag (en daarmee de basisboete) vast te stellen.
62. Met inachtneming van zijn inkomens- en vermogenspositie stelt de Raad voor het feitelijk leidinggeven door de heer [A] aan de beide overtredingen van RMC, zoals vastgesteld in zijn besluiten met kenmerken 7130/153 en 7131/168, tezamen één boetegrondslag, en daarmee één basisboete van EUR 120.000 vast.
63. De Raad kan de basisboete nog bijstellen, wegens boeteverhogende of –verlagende omstandigheden. De Raad ziet ten aanzien van beide overtredingen geen aanleiding voor een boeteverhoging dan wel boeteverlaging. De door de heer [A] aangevoerde verminderde mate van verwijtbaarheid, waarmee slechts een symbolische boete gerechtvaardigd zou zijn, doet naar het oordeel van de Raad geen opgeld. Hij verwijst daartoe naar paragraaf 6 van het onderhavige besluit.
64. Alles overwegende is de Raad van oordeel dat een boete van EUR 120.000 voor het feitelijk leidinggeven door de heer [A] aan de overtredingen van RMC, zoals vastgesteld in zijn besluiten met kenmerk 7130/153 en 7131/168, passend is.
65. Gelet op het voorgaande stelt de Raad de boete vast op EUR 120.000.

VIII. Besluit

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit:

legt aan de heer [A], geboren op [vertrouwelijk] te [vertrouwelijk], een boete op van EUR 120.000

Datum: 20 november 2012

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
namens deze:

Wg.

Henk Don

Lid van de Raad van Bestuur

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.